

1501445-07.2019.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/02/2022

... Lei de Drogas, pois evidenciada a prática do tráfico de entorpecentes na companhia do adolescente. Por fim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda, os elementos dos autos que apontam no sentido de que a ré integrava grupo que praticava o tráfico de forma estruturada, denunciando maior reprovabilidade da conduta, o regime inicial de cumprimento deve ser o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1501445-07.2019.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501445-07.2019.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAINA JOSIANE ELEUTERIO DOS SANTOS MOURA

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Thainá Josiane Eleuterio dos Santos Moura foi denunciada pelo Ministério Público porque, no dia 25 de dezembro de 2019, no período da tarde, na Rua Gilberto de Oliveira Ribeiro, nº 271, bairro Areão, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Yuri Adriano Faria de Souza, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurado pela acusação, na data dos fatos, a ré agindo em conluio com o adolescente Yuri Adriano, trazia consigo, dentro de uma caixa de remédios, 23 pedras de crack, substância entorpecente derivada da cocaína, com peso líquido aproximado de 3,39g, e, ainda, guardava outras 29 pedras da mesma droga, com peso líquido aproximado de 4,02g, dentro de um cano de água localizado próximo ao local onde estavam.

Ocorre que, para apurarem a notícia da prática do tráfico de drogas no local,

policiais militares para lá se dirigiram, oportunidade em que visualizaram a ré, o adolescente e outro indivíduo, usuário de drogas, sendo que a ré, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou ao solo a caixa onde estava parte da droga, o que foi presenciado pelos agentes públicos.

Em ato contínuo, foi realizada a abordagem e, em busca pessoal, foram localizados R\$ 17,00 na posse do adolescente Yuri Adriano.

Após diligências pelo local, os milicianos localizaram a droga dispensada pela ré e a droga camuflada no interior do cano, além da quantia de R\$19,00.

Assim, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, da quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, resultou certo que o entorpecente apreendido seria destinado ao comércio ilícito.

Busca, assim, a condenação da ré como incurso no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 59/61.

Citada (fls. 70), a ré apresentou resposta escrita à acusação às fls. 106/111.

Designou-se audiência, realizada às fls. 153/154, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Leonardo Vieira Barreto de Castro e Guilherme Coutinho de Araújo. Ato contínuo as partes insistiram na oitiva da testemunha Paulo Ricardo.

Em nova audiência designada, foi ouvida a testemunha, Paulo Ricardo de Oliveira Pimenta, procedendo-se ao interrogatório da ré, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência do pedido alegando que a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Afirmou que o relato apresentado pela ré é mendaz, uma vez que se verifica das imagens da câmera do COI que, por volta das 16h20min, o adolescente Yuri estava pelo local na companhia dela (que segurava seu filho no colo) e Guilherme. Sustentou que a justificativa apresentada por ele também é mendaz, quando da abordagem policial, e provavelmente também participava do comércio de drogas que ali era realizado, tanto que atualmente está preso pela prática desse delito. Por volta das 16h25min, o adolescente deixa o local na companhia de outras pessoas, de bicicleta, logo após a passagem de uma viatura policial na rua transversal. Guilherme e Thainá permanecem na via pública, sendo que, por volta das 16h31min, a ré, após a passagem de policiais da ROCAM, se aproxima de Guilherme, que estava sentado na calçada, pega dele um pequeno pacote que estava escondido no local onde ele estava sentado e o coloca em suas vestes, junto aos seios, o que provavelmente era a droga por ela dispensada quando da chegada da guarnição policial. Por volta das 16h39min, Yuri retorna, também de bicicleta, oportunidade em que se juntou a ela, Guilherme e outras duas mulheres que ali estavam sentadas na guia da calçada, tendo Thainá ingressado em sua residência e, ao sair, entregado uma sacola a Yuri, a qual é colocada por ele junto à guia da calçada, provavelmente dentro de um cano de água pluvial, onde parte do entorpecente foi encontrado, e, alguns minutos depois, chegam os policiais militares e fazem a abordagem de todos eles juntos e passam a vasculhar e encontram a droga apreendida nos autos. Ressaltou que as imagens da câmera do COI acabam por desmentir o relato oferecido por ela e reforçam a credibilidade do relato dos policiais militares, pois evidenciam o envolvimento da ré na atividade do tráfico de drogas naquele local. Requereu a condenação nos exatos termos da denúncia. Em relação à fixação da pena, em sua primeira fase, vislumbrou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis à ré, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, que é expressiva, o que demonstra que ela não era pequena traficante. Além disso, o fato de que a droga por ela

comercializada é considerada de maior lesividade. Mencionou que ela trazia consigo, dentro de uma caixa de remédios, 23 pedras de crack, substância entorpecente derivada da cocaína, com peso líquido aproximado de 3,39 gramas, sendo que ela dispensou a sacola ao perceber a presença da viatura policial, o que foi visualizado pelo policial militar Leonardo Vieira e, ainda, guardava outras 29 pedras da mesma droga, com peso líquido aproximado de 4,02 gramas, fato que justifica um aumento da pena-base. Destacou que a própria lei de drogas indica que a natureza e quantidade de entorpecente apreendido devem servir como parâmetro para fixação da reprimenda. Ressaltou, ainda, que a substância apreendida em poder da ré - conhecida como "crack" - é sabidamente mais danosa do que a maconha, tanto porque produz maior dependência física e psíquica, como também porque traz ao usuário risco elevado de morte, em decorrência das alterações que provoca no organismo. Na segunda fase não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase de dosimetria da pena, alegou ser incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da quantidade significativa de droga apreendida, demonstrando que a ré estava envolvida de forma habitual na atividade criminosa. Postulou o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, pois evidenciada a prática do tráfico de entorpecentes na companhia do adolescente. Por fim, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e, ainda, os elementos dos autos que apontam no sentido de que a ré integrava grupo que praticava o tráfico de forma estruturada, denunciando maior reprovabilidade da conduta, o regime inicial de cumprimento deve ser o fechado, conforme permite o artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição da ré. Preliminarmente, afiançou a quebra da cadeia de custódia. Mencionou que cadeia de custódia é a correta aplicação dos procedimentos destinados a assegurar a originalidade, a autenticidade e a integridade do elemento probatório, assegurando assim, a idoneidade e transparência na produção desses elementos. Em apertada síntese, afirmou que a importância da cadeia de custódia está diretamente endereçada à integridade da prova. Portanto, eventual quebra da cadeia de custódia importa na ilicitude da prova a que se refere aquele conjunto de atos, acrescentando ainda que a consequência deve ser a proibição de valoração probatória com a consequente exclusão física dela e de toda a derivada. Salientou, também, que o artigo 158, e seguinte do Código de Processo Penal, normatizam o procedimento para a esmerada manutenção da cadeia de custódia, procedimento não adotado na sua integralidade pelos agentes na coleta e manuseio das provas. No caso concreto, manifestou que há a falta de lacre no recebimento, acondicionamento e no manuseio da suposta substância entorpecente, conforme descrito no boletim de ocorrência. Nesse sentido, reiterou que não houve o devido cuidado no manuseio dos entorpecentes pela autoridade policial, assim como não foi acondicionado de forma correta e não foi lacrado. Ademais, citou que, após serem enviados os dois invólucros com lacre de nº 0005012 e lacre de nº 0005010 ao ICP, para laudo de constatação, o perito recebeu os dois invólucros, mas, ao acondicionar e fazer a remessa do entorpecente ao ICP de São José dos Campos, infringiu o artigo 158-D, § 1º, do Código de Processo Penal, não individualizando os lacres de acordo com as porções recebidas do DP e usando um número de lacre para duas provas distintas, lacre nº 0046754, o que comprova a falta de individualização do material entorpecente, contaminando a cadeia de custódia de forma insanável. Sustentou, também, que os depoimentos dos policiais foram bastante contraditórios, com relação as alegações de que solicitaram a presença de policial feminina ao local, contraditas pelas imagens das câmeras de vigilância. Além disso, segundo as imagens da câmera do COI, o operador conduzia a abordagem e foi dando as coordenadas aos policiais militares, momento em que a testemunha Guilherme foi levada da calçada pelos policiais e colocada no centro da rua, rosto voltado para o local da câmera para verificação do operador e retornou à calçada, o mesmo procedimento foi adotado pelos milicianos com o menor Yuri e a ré Thainá e apesar da ajuda externa, nada foi encontrado. Outrossim, segundo o laudo pericial, foi encontrada uma caixa de papelão vazia, escrita FLUCONAZOL 150 mg, que foi devolvida a autoridade requisitante com lacre nº SPTC

0046753, todavia, não aparece nos autos, sendo mais uma quebra da cadeia de custódia, bem como as imagens indicam que a ré usava camiseta regata e bermuda, portanto, a caixa não poderia ter sido colocada junto aos seios, devido ao tamanho, haja vista a indumentária usada para dias quentes. Diante do exposto, postulou que seja acolhida e ponderada a quebra da cadeia de custódia, sobejamente demonstrado o manuseio inadequado, falta de lacre, não individualização do lacre, com contaminação das provas, bem como seja declarada a nulidade e seja julgada improcedente a presente ação, absolvendo-se a ré, nos termos do artigo 386, incisos IV e V do Código de Processo Penal, como medida de inteira justiça. Caso não seja esse o entendimento, pleiteou que a ré possa responder em liberdade, haja vista, ser mãe de recém-nascido que precisa dos cuidados da genitora e sempre compareceu aos atos judiciais quando intimada, mantendo conduta irrepreensível na medida cautelar. Além do mais, pediu que o tempo da prisão cautelar seja detraído do quantum da pena cominada. Destarte, diante das condições totalmente favoráveis a ré, do preconizado no artigo 59, do Código Penal, requereu que seja cominada pena mínima e o regime de cumprimento seja o aberto, podendo ser convertido em penas alternativas.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação da ré como incurso no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Antes de tudo, impende afirmar, com relação à petição de fls. 217/219, manejada pela Defesa, que não existiu qualquer nulidade na ata de audiência.

Com efeito, a audiência foi gravada e os fatos passados da gravação constam. O fato de a testemunha – Paulo Ricardo – ter-se ausentado do “lobby” virtual e haver ingressado posteriormente, quando contactado pela escrevente, não traz qualquer prejuízo ao réu, tampouco à lei posta.

De outro lado, referida testemunha disse no seu depoimento que não se lembrava dos fatos, mesmo após a leitura da denúncia pelo Promotor. Assim, franqueada a palavra ao Defensor, a intervenção deste Juízo quando da formulação de pergunta que se referia ao fato foi absolutamente legal, justamente porque a testemunha já havia explicitado que não se lembrava dos fatos. Cabe aduzir, nesse ponto, que ao Juiz incumbe presidir a audiência, de modo a conduzi-la da melhor forma possível, sem incidentes ou atos desnecessários. A pergunta, naquele momento, já havia sido respondida anteriormente, ao dizer que não se recordava dos fatos. Dessa forma, a mera repetição da pergunta não era pertinente e nem relevante aos autos, justamente porque já a havia respondido ao declarar que não se recordava dos fatos.

Assim, nenhuma ilegalidade se observa na ata ou mesmo na conduta do Juízo.

Por outro lado, a despeito da afirmativa em contrário da Defesa, o link referente às imagens do COI está em pleno funcionamento, tanto que as imagens foram aferidas por este magistrado, fazendo uso do link de fls. 143. Consta, inclusive, a filmagem da audiência de custódia.

Quanto às questões preliminares, importa afirmar que não houve a alegada quebra da cadeia de custódia.

Registre-se que às fls. 11 a droga encontrada foi devidamente lacrada sob os números 5012 e 5010.

Logo depois da apreensão a droga foi enviada ao IC-CP de São José dos Campos,

sobrevindo o laudo pericial 489560/2019 (fls. 12/16), sendo aferida a droga constante dos lacres 5012 (item 1) e 5010 (item 2). A sobra, devidamente separada e embalada, foi novamente lacrada sob o número 46753, assim como a caixa de papelão vazia.

Registre-se, nesse ponto, que os itens foram separados e embalados – apesar de se tratar da mesma droga – e o fato de serem acondicionados em um outro recipiente, também devidamente lacrado, não traz nenhuma nulidade como afirma a Defesa.

Nesse passo, verifica-se que a inviolabilidade dos recipientes usados e sua individualização e idoneidade foram devidamente preservadas, tanto que possibilitou a realização do laudo definitivo, apontando, detidamente, cada qual dos itens, 1 e 2 (fls. 75/77).

Dessa forma, impende rejeitar a alegação, justamente porque a prova foi colhida da maneira determinada pela lei, mantida sua integridade.

Sem outras questões a se enfrentar, de se dizer que as condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 2/5), termos de depoimentos (fls. 6/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), laudo pericial provisório (fls. 12/16), termo de declarações (fls. 17), termo de interrogatório (18), laudos periciais definitivos (fls. 75/77 e 100/102) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste a acusada, em razão da robusta prova atribuindo a ela a prática do crime de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente.

A testemunha Guilherme Coutinho de Araújo, ouvida em juízo às fls. 153/154, disse que não sabe de nada e que somente foi pego junto com a ré. Alegou que não sabia do envolvimento dela com o tráfico de drogas e nem os conhecia de lugar nenhum. Informou que está preso por tráfico e porte desde setembro. Acrescentou que não viu a abordagem da ré e não sabe se ela tinha entorpecentes.

A testemunha Leonardo Vieira Barreto de Castro, ouvida em juízo às fls. 153/154, disse que estavam em patrulhamento e quando viraram a rua visualizaram a ré dispensando uma caixa, razão pela qual a abordaram. Alegou que durante a revista nada de ilícito foi encontrado com a ré, todavia na caixa de remédio dispensada por ela havia pedras de crack. Informou que durante a varredura no local encontraram mais pedras de crack em um cano de água, acerca das quais Yuri, o menor que estava junto, assumiu a propriedade. Acrescentou que questionada a ré, ela negou a propriedade dos entorpecentes e por estar realizando o tráfico. Afirmou que não conhecia a ré, porém anteriormente já tinha abordado Yuri. Declarou que ao conversar com Guilherme, que também foi abordado no mesmo local, ele informou que estava ali porque é usuário e tinha ido comprar maconha, porém foi informado pela ré que somente tinha crack. Alegou que não foram até a residência da ré. Acrescentou que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Afirmou que viu a ré dispensar os entorpecentes, assim como o seu companheiro que estava de moto. Informou que além dele e de seu parceiro, tinha a viatura do tenente e a policial feminina, os quais chegaram pouco tempo depois deles. Esclareceu que a caixa com drogas dispensada pela ré estava próxima a ela e que ele a recolheu após fazer a revista pessoal dos dois rapazes que ali estavam. Disse que a ré estava em pé quando a viram. Alegou que não sabe a razão pela qual os abordados foram levados para rua. Afirmou que na calçada onde fizeram a abordagem tinha mais pessoas.

A testemunha Paulo Ricardo de Oliveira Pimenta, ouvida em juízo, declarou que não se recordava da ocorrência apurada nos autos.

A ré Thainá Josiane Eleutério dos Santos Moura, interrogada em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e negou que seja verdadeira. Justificou que estava sentada na calçada com sua irmã e uma amiga, quando Yuri apareceu e lhe pediu uma sacola. Nesse cenário, ele pediu que ela segurasse a sacola e jogou algumas moedas dentro, saindo logo em seguida com sua bicicleta. Pouco tempo depois, ocorreu a abordagem, feita por uma policial feminina, a qual não encontrou nada de ilícito e ela foi liberada. Todavia, posteriormente, apareceu um outro policial e avisou que iria prendê-la, encaminhando-a à Delegacia. Garantiu que não havia entorpecentes em sua posse ou em qualquer local próximo à sua casa. Não soube dizer sobre os outros abordados, bem como não viu a caixa de remédios. Afirmou, ainda, não ser usuária de drogas. Ademais, alegou não ter contato com Yuri e não conhece Guilherme. Asseverou que as drogas que supostamente estavam em sua posse só lhe foram apresentadas na Delegacia. Disse ser solteira, tem 23 anos e 2 filhos, além de morar com a mãe; trabalha como manicure, com renda média de R\$ 50,00 por dia; não tem outros processos.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Observo que a conduta da ré se enquadra em diversos verbos do núcleo do tipo, notadamente trazer consigo drogas, resultando, assim, configurada a tipificação do crime em destaque.

Os policiais ouvidos disseram que ao avistarem a ré, a viram dispensando uma caixa de remédios sendo que seu interior estavam as drogas, sendo outras encontradas em local próximo, dentro de um cano.

Além disso, há imagens do COI, que demonstram a conduta da ré pouco antes e durante a abordagem, especialmente recebendo algo das mãos de Guilherme e o escondendo junto aos seios.

A despeito do silêncio da ré na delegacia, a palavra dos policiais se soma às drogas encontradas, não havendo dúvida do tráfico praticado pela ré, que implica sua responsabilização.

Anoto, nesse ponto, que os depoimentos prestados pelos policiais são coesos e harmônicos, inclusive reproduzindo, com fidelidade, o quanto afirmado no depoimento prestado na Delegacia de Polícia, dando conta do ocorrido na data dos fatos.

A propósito da questão, pacífico nos tribunais, inclusive nos superiores, que "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos." (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013).

Ressalta-se que os agentes policiais, no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância.

Em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

Não há razão para duvidar da palavra dos policiais que prestam serviço público de enorme utilidade à sociedade, mormente porque seus depoimentos encontram escoro nas demais provas idôneas produzidas nos autos.

O Estado credencia os policiais para o exercício da repressão criminal outorgando-lhes certa parcela do poder estatal e o Judiciário empresta essa mesma credibilidade quando chamados a prestar contas do exercício de sua função.

Por outro lado, não há dúvida do envolvimento no delito do adolescente, que se encontrava no local com a ré, inclusive assumiu informalmente aos policiais parte da droga encontrada como de sua propriedade.

Nesse passo, incide o disposto no inciso VI, do artigo 40, da Lei 11.343/06.

Não há, assim, qualquer dúvida acerca da responsabilidade da ré pelo delito de tráfico e do envolvimento do adolescente no delito.

Impõe-se, outrossim, reconhecer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4.º, da Lei 11.343/06.

Registro, pelo que se depreende das provas colhidas, que a ré é primária e tem bons antecedentes.

Nada há que demonstre ser ela dedicada a atividades criminosas ou faça parte de organização criminosa.

Ao que tudo indica, não se trata de traficante habitual, sendo justamente àqueles que a lei visa a conceder a benesse, promovendo-lhes uma nova chance para que se ajustem ao meio social em que vivem.

A propósito, sobre o tema ensina Sérgio Ricardo de Souza: "O agente verdadeiramente primário e de bons antecedentes, que tenha infringido as condutas previstas na cabeça do art. 33 e no seu § 1º, tem o direito subjetivo a esta causa especial de diminuição de pena, extremamente significativa, (...) desde que ele não seja um profissional do crime (não se dedique) às atividades criminosas, nem integre alguma organização criminosa. Trata-se de uma opção do legislador por "separar o joio do trigo danificado", aumentando o rigor em relação àquele e criando opções de minimizar a punição em relação a este, que em tese se encontra em uma situação onde a reinserção social é mais viável." (Nova Lei Antidrogas - Lei nº 11.343/06: comentários e jurisprudência. Niterói: Editora Impetus, 2006, p. 45).

Faz, jus, assim, à diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

A ré era, na data dos fatos imputável. Tinha plena consciência da ilicitude do ato praticado e podia determinar-se de forma diversa, preferindo, porém, o crime. Não concorrem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

A prova é certa, segura e aponta para o cometimento do crime pela ré, devendo ser responsabilizada.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A despeito da natureza da droga, de grande poder vulnerante, observo que a

quantidade de que dispunha não pesa em seu desfavor, podendo ser considerada dentro da normalidade dos casos atinentes ao tráfico de droga.

No que se refere à personalidade da ré - que no entender de Guilherme Nucci é aquela que está vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da pena, RT, 2005, p. 207) - se mostra negativa.

Isso porque resultou claro que ela mentiu em Juízo quando alterou a versão dos fatos ocorridos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, visando a uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte dela, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta à dignidade da justiça, colocando em dúvida a integridade dos policiais militares ao dizer que não teve conhecimento das drogas até chegar na delegacia.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que ainda que seja o interrogatório um meio de defesa e de prova, evidente que a ré deve respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para a realização da Justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para os acusados, como também para a sociedade.

Ora, é forçoso reconhecer que o acusado ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa - que não é absoluta - demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a Justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta.

Afigura-se evidente que não se pode tolerar que o acusado se valha de engodos, ardis e mentiras visando a escapar de uma justa condenação. O acusado que assim age, frauda a produção de provas e torna o processo uma chicana pessoal e egoísta, revelando sua personalidade dissimulada, amoral, o que justifica a elevação da pena.

Acerca do tema, pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar - até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente".

O entendimento acima explicitado, ainda que minoritário na jurisprudência, tem sido prestigiado em várias decisões judiciais, cabendo o registro, por todas, de parte do judicioso voto da lavra do Desembargador José Raul Gavião de Almeida, na Apelação 00771651-20.2015, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 30 de novembro de 2017 :

"...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade"

Ainda sobre o tema, se revela oportuno registrar parte do artigo " A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", da lavra do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Cleber Pereira Defina, que de forma judiciosa analisou o

tema:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarividente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (*nemo tenetur se detegere* ou *privilege against self incrimination*); contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade, ao revés, deve o julgador, por ocasião da individualização da pena, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado em juízo, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo.

Não se pode olvidar, ainda, que o réu, desde a promulgação da Lei 11.719/2008, é interrogado após a colheita de todas as provas, inclusive depoimento das testemunhas, de forma que tem plena consciência das provas produzidas e da sua repercussão, mormente em razão da defesa técnica que o assiste, razão pela qual a sua opção pela mentira se mostra ainda mais censurável, cínica e abjeta, pois abre mão do direito ao silêncio, e até mesmo da atenuante da pena da confissão, para tentar induzir em erro o juízo e assim ferir a dignidade da justiça.

A propósito, impende registrar, por relevante, que caso o julgador não aumente a pena do acusado mendaz, "estará incentivando o réu a sempre mentir, afinal, se sua mentira não lhe causa qualquer prejuízo, podendo, inclusive, livrá-lo de uma condenação justa, por que confessar um crime ou mesmo ficar em silêncio? Não punir o acusado mentiroso, aliás, viola o princípio da individualização da pena, pois equipara equivocadamente a situação do réu que fica em silêncio em seu interrogatório, com a do que mente descaradamente, em verdadeira afronta à dignidade da Justiça, pois tem o único propósito de induzir esta em erro, minando, assim, sua credibilidade perante a sociedade" ("A mentira do réu e a Dosimetria da Pena", artigo de autoria do Promotor de Justiça, Dr. André Wagner Melgaço Reis, publicado na rede mundial de computadores, no endereço

<http://www.cartaforense.com.br/autor/andre-wagner-melgaco-reis/958>).

Nesse passo, cabe trazer recentíssima decisão proferida pelo voto do i. Desembargador Tetsuzo Namba:

“...demais disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o patrocínio indevido da “não verdade”, isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP – Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28.11.2019).

Cabe anotar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento recente, por votação unânime, decidiu no mesmo sentido da tese que ora se adota, trazendo excertos de decisão proferida por este juízo como razão de decidir, como se infere dos autos da Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Roberto Porto:

“Ademais, como bem destacou o Ministério Público a fl. 277 o fato de o réu ter mentido em Juízo, trazendo aos autos fatos absolutamente inverídicos, revela sua personalidade desvirtuada, devendo ser considerado no momento da exasperação da reprimenda. Aliás o Douto Magistrado bem fundamentou a exasperação da pena-base...”

No mesmo sentido já decidiu a Colenda 14^a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime nos autos da apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, de relatoria do ilustre Desembargador Walter da Silva:

“(...) Em relação ao delito previsto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03: Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na personalidade negativa do apelante, pois demonstrou perante o Juiz desonestidade e insinceridade, o que revelou a distorção de caráter, e assim a reprimenda foi tornada definitiva na ausência de outras causas modificadoras.”

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, com enfoque na personalidade desviada, em voto proferido pela 6.^a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pela voz do ilustre relator Zorzi Rocha, assentou:

“Dessa forma, se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça” (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, j. 3.10.2019).

Não outra a conclusão a que chegou o ilustre Des. Ricardo Sale Júnior, chamando atenção para a correção do decisor que elevou a pena-base pelo fato de haver o réu mentido ao ser interrogado em juízo “fato que evidencia uma personalidade voltada para o crime” (TJSP – Apelação Criminal 0002205-19.2013.8.26.0625, 15.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 8.8.2019).

No mesmo sentido o voto da lavra do ilustre Des. Tetsuo Namba, ao aduzir correta a

sentença que reconheceu a mentira do réu como personalidade deturpada, justificando-se a elevação da pena na primeira fase da dosimetria. (TJSP – Apelação Criminal 0001091-27.2017.8.26.0618, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. em 5.12.2019).

Também em processo que teve trâmite por esta 3.^a Vara, em sede de apelação (Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625), a i. Desembargadora Ivana David, assentiu com a tese ora perfilada, nos termos seguintes, fazendo alusão, em parte, à decisão proferida nos autos do Processo Criminal nº 0003339-30.2014.8.26.0372, 1.^a Vara Judicial de Hortolândia - Juiz de Direito, Luis Mário Mori Domingues j. 21.01.2015.

“E escorreita a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, “nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. Em momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo”, demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 10.12.2019).

No que respeita à culpabilidade o que se vê é natural à espécie.

Não ostenta a ré maus antecedentes, sendo primária.

Acerca da conduta social da ré não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico a saúde pública, não havendo, então, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, na fixação da pena-base, toma-se a personalidade negativa da ré para acrescer à pena mínima cominada em abstrato 1/6, elevando-a a 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda fase não há circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual fica mantida em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na terceira etapa, aferida a causa de diminuição posta no artigo 33, §4.º, da Lei de Drogas, impõe-se reduzir a pena em 2/3, que assim passa a totalizar 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa. Reconhece-se, outrossim, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma lei, impondo-se aumentar a pena em 1/6, elevando-a a 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, além de 226 dias-multa.

Quanto ao regime inicial, de se lembrar que o tráfico privilegiado não ostenta natureza hedionda (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 118. 533/MS) o que se soma à pequena quantidade de entorpecente e aos bons antecedentes da ré, demandando, nesse caso, o regime aberto.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira da ré, devendo ser atualizado pelos índices de

correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação da agente e à repreensão do direito. Verifico que no caso em exame a ré demonstrou personalidade negativa e, ainda, envolveu adolescente no delito. Não se trata daqueles casos em que a acusada colabora com a Justiça, confessando os fatos, sem o envolvimento de adolescente, situações em que este Juízo entende que faz jus à substituição. A situação em exame é relativamente mais grave e afasta a possibilidade de substituição.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anoto, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente'" (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade. Anoto que no decorrer do processo ela esteve em liberdade, não se vislumbrando necessidade de alteração desse estado, prestigiando assim a presunção da inocência, pois ausentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar.

Como afirma Ricardo Schmitt, "como regra geral, temos que se o sentenciado se encontra solto, em liberdade plena no momento da sentença, tendo permanecido nesta situação durante a instrução processual, em princípio possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se existir algum motivo ponderoso à aplicação de medida cautelar diversa da prisão, ou, em último caso, de decretação de sua custódia preventiva" (Sentença Penal Condenatória, 8.ª ed., Editora JusPodivm, Bahia, 2014, p. 443)

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito da ré por conta do período que ela permaneceu presa cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes - 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento do dinheiro, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e artigo 63, da Lei 11.343/06, pois o valor apreendido se trata de produto da traficância.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para condenar a ré Thainá Josiane Eleuterio dos Santos Moura à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, além de 226 dias-multa, como incursa no artigo 33, caput, e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, com início de cumprimento no regime aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, condenando-a, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar a ré para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação da ré;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 18 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA